

1500381-18.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... cerca de oitenta cigarros, justifica a presunção de tráfico, sendo inadmissível o acolhimento da alegação de uso próprio sem prova cabal e irrefutável nesse sentido, ônus então da defesa". (Relator: Luiz Pantaleão - Apelação Criminal n. 139.646-3 - Araçatuba - 28.06.93).

"TRÁFICO - Tóxico - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimento dos policiais - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500381-18.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500381-18.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097848/2022 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 24196179 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2097848 - 01º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERNANDO MEDEIROS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

JEFERSON LINO CORREIA e HERNANDO MEDEIROS DA SILVA, com dados qualificativos às fls.12 e 17, estão sendo processados por incursos no artigo 33, caput, e no artigo 34, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, por que, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 20h10, na Rua José Luís Covolan, nº 514, no Residencial Furlan, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, agindo em concurso de agentes, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 03

(três) tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha, com cerca de 2.845,0g; 01(um) porção de maconha, com cerca de 400,0g; e, mais 2.135 (duas mil, cento e trinta e cinco) porções da mesma substância entorpecente, com cerca de 2.135,0g, fazendo-os sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no item "I", nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, JEFERSON LINO CORREIA e HERNANDO MEDEIROS DA SILVA, já qualificados, possuíam e mantinham em depósito, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, mais precisamente, 01 (uma) marreta de borracha, 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) facas e 12 (doze) pacotes de plásticas, tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, os denunciados, em circunstâncias ainda não apuradas, obtiveram a posse das drogas descritas acima para entrega ao consumo de terceiros, bem como dos maquinários e instrumentos destinados ao embalo de drogas.

Ainda segundo foi apurado, guardas municipais receberam informação via CICOMM, de que na residência situada no endereço supramencionado, havia vários indivíduos fracionando drogas e que, por volta das 20h30, uma pessoa iria até a residência para pegar os entorpecentes para distribuição em pontos de venda. Assim é que, visando a apuração dos fatos, os agentes se dirigiram ao local e avistaram os denunciados na garagem do imóvel e, se dirigiram a eles informando o teor da denúncia e solicitando autorização para ingressar ao imóvel. HERNANDO, identificado como proprietário do imóvel, após dizer que a "casa tinha caído", franqueou a entrada da guarda.

Realizada as buscas no imóvel, na cozinha, sobre a mesa, os agentes encontraram uma farta quantidade de maconha, dividida em 03 (três) tijolos, 01 (uma) porção a granel e 2.135 (dois mil, cento e trinta e cinco) porções já fracionadas e prontas para a venda. No local também foram apreendidas 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) facas, 01 (uma) marreta de borracha e 12 (doze) pacotes de embalagens de plásticos.

Questionados pelos agentes, HERNANDO admitiu o crime, afirmando que receberia R\$500,00 para fracionar e guardar as drogas. JEFERSON negou o crime, afirmando que estava no local para consumir "crack".

Interrogados na Delegacia de Polícia, HERNANDO e JEFERSON optaram em permanecer em silêncio (fls. 16 e 20).

Os acusados foram notificados (fls. 221 e 222) e apresentaram defesa preliminar (fls. 218/220). A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls. 223/224) e os réus foram citados (fls. 236 e 240). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogando-se os acusados ao final.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência da ação, face a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, ou em caso de condenação, fixação da pena no patamar mínimo, com regime de cumprimento mais brando.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do

boletim de ocorrência a fls. 38/40, auto de apreensão e exibição a fls. 27/28, auto de constatação do entorpecente apreendido a fls. 08/09, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 108/110, o qual detectou a presença da substância tetrahydrocannabinol, e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Ailton Sandrin e Antônio Araújo deram versões essencialmente iguais. Disseram que receberam via Cicom uma denúncia indicando que numa residência do bairro Residencial Furlan indivíduos estavam fracionando drogas para posterior abastecimento de biqueiras, e que as drogas seriam retiradas do local por volta das 20:30h. Que foram ao local e se depararam com os acusados na garagem da residência. Que Hernando se identificou como proprietário do imóvel, e após cientificá-lo das denúncias, ele já admitiu que havia drogas na casa, autorizando o ingresso. Que sobre a mesa da cozinha havia três tijolos de maconha, uma porção a granel, e 2135 porções de maconha já embaladas, além de balança de precisão, facas, marreta de borracha, pacotes plásticos para embalo da droga. Que Hernando disse que cedeu a casa por R\$ 500,00 para outros indivíduos irem ao local prepararem a droga, enquanto Jeferson disse que era usuário de crack e estava no local fazendo uso da droga. Que Jeferson não aparentava estar sob efeito de drogas, nem havia resquícios de consumo da droga crack no local. Que não havia indícios de comercialização de droga, apenas de preparo mesmo. Que os petrechos localizados eram utilizados para preparar a maconha, e não outros tipos de droga.

O acusado HERNANDO MEDEIROS DA SILVA, em seu interrogatório, disse que é usuário de crack e estava devendo R\$ 1500,00 aos traficantes por conta do seu vício. Que então aceitou ceder seu imóvel para eles prepararem a droga. Que a cada um tijolo preparado, ele receberia R\$ 500,00. Que cinco rapazes, aproximadamente, chegaram na sua casa no início da tarde, e eles ficariam até umas 19:30h preparando as drogas. Que saiu de casa, não ficou com eles, e quando voltou, nesse horário, eles não estavam mais, mas a droga ainda estava sobre a mesa. Que logo em seguida os guardas municipais chegaram na sua casa e lhe surpreendeu com as drogas e os materiais de embalo. Que quando saiu, de tarde, ficou com Jefferson na rua usando drogas, e depois voltou. Jeferson foi para casa tomar banho e depois foi para sua casa. Cerca de dez minutos depois os guardas municipais chegaram, e Jefferson foi abordado junto. Que chegou a avisar Jefferson que havia drogas na casa, mas ele disse que ficaria mesmo assim. Que havia cinco tijolos de maconha, então receberia R\$ 2.500,00 por ceder a casa. Que usou drogas com Jefferson antes dos guardas chegarem. Que são amigos há anos. Que morava sozinho na casa, que é herança dos pais. Que já trabalhou como pintor e estava fazendo bicos.

O acusado JEFERSON LINO CORREIA, em seu interrogatório, disse que naquele dia trabalhou durante o dia, voltou para casa e saiu para ir até a casa de Hernando. Que tinha comprado duas pedras de crack e levou na casa dele, para usarem juntos. Que assim que chegou, cerca de dez minutos depois, os policiais chegaram e lhe abordaram. Que estava deitado na rede quando os policiais chegaram, e o Hernando estava lá dentro, pois foi pegar água. Que já tinha consumido as drogas quando os guardas chegaram. Que não viu drogas no interior da casa, mas Hernando avisou que havia drogas lá, mas disse a ele que ficaria pouco tempo e iria embora. Que estava na sua casa com seus familiares antes de ir para a casa de Hernando. Que conhece Hernando há anos, e eles usam drogas juntos.

As versões trazidas a Juízo, em que ambos buscam se eximir da responsabilidade penal pelo crime de tráfico, encontra-se em total divergência com todas as demais provas coletadas, o que torna a alegação desprovida de elementos que as consubstanciem.

Ambos foram surpreendidos na posse de elevada quantidade de droga, algumas ainda de forma bruta, em tijolos, outras já prontas, além de material de preparo e embalo,

revelando que ambos estavam manipulando aquela droga antes da chegada dos guardas municipais.

As versões dos acusados restaram contraditórias. Hernando disse que saiu de casa para outros manipularem a droga, e que permaneceu na rua com Jefferson até seu retorno, por volta das 19:30h, alegação esta que não foi confirmada por Jefferson, que disse ter ido à residência de Hernando por volta das 19:30h, mas não estava com ele antes deste horário.

Jefferson disse que estava na sua casa antes de ir para casa de Hernando, com familiares, mas nenhuma dessas pessoas foi trazida em Juízo para corroborar essa versão, o que era plenamente possível fazê-lo, já que são membros da própria família.

Fato é que sendo surpreendidos nas circunstâncias que o foram, ou seja, numa residência contendo drogas sobre uma mesa de cozinha, bem exposta, num cenário de plena manipulação e preparo destas, competia aos acusados comprovar que terceiros estavam realizando tal tarefa, e não eles, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, do que não se desincumbiram, já que nada há nos autos que ampare as alegações trazidas em Juízo.

No mais, os guardas municipais foram uníssonos em afirmar que não havia nenhum resquício de consumo de droga no local, nada relacionado ao entorpecente crack, e que ambos não aparentavam estar sob efeito de drogas, o que também afasta a alegação de que estavam fazendo uso desta droga antes dos guardas chegarem.

E não há porque duvidar das alegações dos guardas municipais, pois não se verificou, em nenhum momento, eventual desavença entre eles ou mesmo a intenção destes agentes em prejudicar pessoas inocentes. E os depoimentos foram firmes, uníssonos e imparciais, e são aptos a ensejar um decreto condenatório, pois nada indica que mentiram em Juízo, ao contrário dos acusados, que têm intenção de apresentar versões exculpatória para se livrarem de uma condenação, ainda que esta seja totalmente inverossímil.

Ademais, os depoimentos destes agentes se mostraram harmônicos e seguros, demonstrando idoneidade, razão pela qual confiro plena credibilidade para firmar meu convencimento.

E a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância do depoimento de policial militar, quanto mais se não existe nenhum elemento nos autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n.

993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

“PROVA. Depoimento policial. Valor. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal Recurso improvido neste aspecto” (Apelação Criminal n.993.08.043553-7, São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal Relator: Newton Neves 09.09.08 V.U. Voto n. 5652).

“PROVA. Depoimento de policial. Validade. Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado. Eficiência. Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva. Ocorrência - Apelação provida parcialmente” (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 São Paulo 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal Relator: René Nunes 28.02.07 M.V. Voto n. 10.200).

Até mesmo a alegação de serem usuários do entorpecente crack não está comprovada nos autos, ônus este pertencente a ambos, de comprovar tal condição, na forma do artigo 156 do CPP: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, não trazendo nenhuma testemunhas para corroborar sua tese.

Nesse sentido:

“TÓXICO - Tráfico - Porte de “tijolinho” de maconha - Quantidade suficiente à confecção de oitenta cigarros - Ônus da demonstração de uso próprio pertencente à defesa - Presunção de destinação comercial - Admissibilidade - Recurso parcialmente provido para outro fim. O agente que, na via pública, traz consigo “tijolinho” de maconha, do qual se pode confeccionar cerca de oitenta cigarros, justifica a presunção de tráfico, sendo inadmissível o acolhimento da alegação de uso próprio sem prova cabal e irrefutável nesse sentido, ônus então da defesa”. (Relator: Luiz Pantaleão - Apelação Criminal n. 139.646-3 - Araçatuba - 28.06.93).

“TRÁFICO - Tóxico - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimento dos policiais - Credibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 6.368/76 - Inadmissibilidade - Finalidade comercial evidenciada nos autos - Diversidade (maconha e cocaína), quantidade e forma de acondicionamento que respaldam a tipificação - Crime de natureza permanente que caracteriza-se com o simples fato de trazer consigo a droga - Ausência, ademais, de prova da exclusividade de uso próprio - Ônus da defesa - Sentença confirmada - Recurso não provido”. (Apelação Criminal n. 290.772-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal “JANEIRO/2000” - Relator: Debatin Cardoso - 20.01.00 - V.U.).

No mais, o só fato do serem usuários de drogas, eventual ou compulsivo, não impede de ser eles ao mesmo traficantes, aliás, tal tipo de comportamento é comum.

Ademais, é notório que para a configuração do tráfico de drogas não há necessidade da prova da sua venda ou cessão, bastando que o entorpecente seja encontrado na posse dos acusados para se atingir tal escopo, daí porque o fato de não ser visualizada a ação de venda ou entrega, ou mesmo a comercialização desta droga, em nada altera a adequação típica de sua conduta.

Sendo assim, diante do conjunto probatório coerente e robusto, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, da quantidade, ou seja, 03 (três) tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por “maconha, com cerca de 2.845,0g; 01(um) porção de maconha, com cerca de 400,0g; e, mais 2.135 (duas mil, cento e trinta e cinco) porções da mesma substância entorpecente, com cerca de 2.135,0g, conforme laudo pericial dos entorpecentes (fls. 107/110), além dos petrechos

destinados em embalo desta droga, tenho como certa a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados, sendo a condenação medida de rigor.

Com relação ao crime previsto no artigo 34 da Lei de Tóxicos, posse dos petrechos destinado ao preparo de entorpecente, impõe-se a aplicação do princípio da consunção.

Este princípio estabelece que na hipótese de uma conduta consistir em meio necessário ou preparatório para consumação de outro delito, acaba por este absorvida, implicando no esvaziamento da norma incriminadora a ponto de possibilitar a ocorrência de um único fato típico.

Sobre o princípio da consunção, preconiza Damásio E. de Jesus que “ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa” (in Direito Penal; 1º volume – Parte Geral, 26ª edição, Ed. Saraiva: 2003, p. 114).

No caso dos autos, os materiais de preparo e embalo foram apreendidos no mesmo contexto fático da prática do delito de tráfico de drogas, é dizer, serviam claramente como meio para finalidade da comercialização da substância entorpecente maconha, existindo, portanto, tão-somente o delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

É como ensina Luiz Flávio Gomes:

“Cuida-se de delito subsidiário, ou seja, praticando o agente, no mesmo contexto fático, tráfico de drogas e de maquinários, deve responder apenas por aquele, ficando este absorvido (o que não impede o juiz de considerar essa circunstância na fixação da pena). Nesse sentido: “Embora se trate de condutas previstas em dispositivos legais distintos (arts. 12 - atual art. 33 - e 13 - atual art. 34), comete somente o delito de tráfico o agente que, no mesmo contexto fático, é surpreendido mantendo sob seu poder e guarda tóxico e na posse de maquinismo para manipular entorpecente”. (“Lei de Drogas Comentada”, Ed. RT, 2ª edição, p. 200).

A jurisprudência não discrepa deste entendimento:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE E GUARDA DE MAQUINÁRIO E DE ESTOCAGEM DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADOS À MANUFATURA DE ENTORPECENTES (ARTS. 12, § 1º, I, e 13 DA LEI Nº 6.368/76, ATUALMENTE PREVISTOS NOS ARTS. 33, § 1º, I, e 34, DA LEI Nº 11.343/06). CONDUTAS TÍPICAS QUE CONSTITUEM MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO DE DELITO DE ALCANCE MAIS AMPLO (FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O princípio da consunção em relação aos crimes de posse e guarda de maquinário e de estocagem de matéria-prima destinados à manufatura de substâncias entorpecentes pode ser aplicado, uma vez que ditas condutas constituem meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de delito de alcance mais amplo, no caso, a fabricação de entorpecente. 2. Conclui-se que o intuito do legislador foi punir, por exemplo, o agente que constrói um laboratório para refino de cocaína, independentemente da sua efetiva produção, ainda que a posse das máquinas e dos objetos em questão não seja, isoladamente, considerada ilícita (tais como, no caso em exame, de baldes e de um liquidificador); ou sancionar aquele que mantém em depósito matéria-prima destinada ao refino ou à produção de drogas, mesmo que a estocagem dessa, por sua natureza, não constitua, per se, crime (no caso concreto, de solução de baterias, livremente revendida com fim específico de regeneração de cargas elétricas em baterias, e de

barrilha, utilizada no tratamento de água para piscinas e para outras finalidades lícitas). 3. No caso em exame, pelo que se vê da denúncia, tanto a posse da matéria-prima, como a dos maquinismos/objetos, visava a um fato único: a produção de entorpecente (merla) pelo paciente naquele local, para posterior comercialização da droga. 4. Está patente nos autos a existência de uma estrutura destinada ao tráfico de drogas, na modalidade de fabricação. 5. Ordem concedida." (HC 100.946/GO, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, J. 25/10/2011, DJe 27/02/2012).

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DE REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA MESMA LEI. PLEITOS INVIÁVEIS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS NORMAS VIOLADAS. RECURSO ESPECIAL COM MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. PEDIDOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DA PROVIDÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA NOS ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. POSSE DE INSTRUMENTOS. CRIME MEIO. 4. BALANÇA DE PRECISÃO E SERRA CIRCULAR. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. OBJETOS PRÓPRIOS DO CRIME DE TRÁFICO. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 2. É assente nesta Corte Superior que cabe ao aplicador da lei, nas instâncias ordinárias, proceder ao cotejo do material fático-probatório dos autos, a fim de aferir a existência de provas aptas a embasar a condenação bem como a correta dosimetria da pena, com incidência das causas de aumento e de diminuição que ficarem comprovadas. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via eleita, o reexame de fatos e provas, conforme dispõe o enunciado nº 7 da Súmula desta Corte. 3. Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem. 4. Salutar aferir, ademais, quais objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver, deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa de caneta - utilizada como medidor -, atrair a incidência do tipo penal em exame. Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a apreensão de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas, pois referidos instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se prestando à configuração do crime de posse de maquinário. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para excluir a condenação dos recorrentes Márcia Regina Millezi e Francisco Luís Alves de Lima pela prática do delito do art. 34 da Lei de Drogas. (REsp 1196334/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013).

Vê-se, então, que em situações como esta dos autos, em que são apreendidas substâncias entorpecentes e petrechos destinados à preparação de drogas dentro do mesmo contexto fático, aplica-se o princípio da consunção, impondo-se a condenação dos acusados apenas pelo crime de tráfico de drogas.

Passo, então, a dosar a pena.

JEFERSON LINO CORREIA

Primeira fase: atenta aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta seis condenações criminais transitadas em julgado (fls. 81/87), sendo que cinco delas as penas foram extintas em fevereiro de 2017 (fls. 82), o que caracteriza maus antecedentes. O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Neste caso em concreto, o acusado guardava e tinha em depósito quantidade elevada de maconha - 03 (três) tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha, com cerca de 2.845,0g; 01(um) porção de maconha, com cerca de 400,0g; e, mais 2.135 (duas mil, cento e trinta e cinco) porções da mesma substância entorpecente, com cerca de 2.135,0g. Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada do entorpecente e maus antecedentes criminais - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Na segunda fase: ausentes atenuantes, e incide a agravante da reincidência genérica (o acusado ostenta uma condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo, Processo nº 0005443-26.2016.8.26.0533, fls. 61), o que autoriza o aumento da pena de mais 1/6, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias multa. Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição, esclarecendo que devido à reincidência do acusado, fica vedado o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Assim, fica fixada, em definitivo, a pena em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

HERNANDO MEDEIROS DA SILVA

Primeira fase: atenta aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado que caracteriza reincidência (fls. 43/58), o que será usado na segunda fase de aplicação da penal. O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Neste caso em concreto, o acusado guardava e tinha em depósito quantidade elevada de maconha - 03 (três) tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha, com cerca de 2.845,0g; 01(um) porção de maconha, com cerca de 400,0g; e, mais 2.135 (duas mil, cento e trinta e cinco) porções da mesma substância entorpecente, com cerca de 2.135,0g. Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada do entorpecente - aumento a pena base de 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Na segunda fase: ausentes atenuantes, e incide a agravante da reincidência genérica (o acusado ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, Processo nº 0004037-33.2017.8.26.0533, por delito de furto qualificado e Processo nº 1500146-56.2019.8.26.0630, por delito de lesões corporais - fls. 45 e 46) o que autoriza o aumento da pena de 1/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias multa. Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição, esclarecendo que devido à reincidência do acusado, fica vedado o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 Assim, fica fixada, em definitivo, a pena em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, além de serem os réus reincidentes, na forma do artigo 33, §2º alínea "b" do CP, denotando a personalidade voltada ao crime, o que exige a imposição do regime mais gravoso

para efetiva prevenção e reparação do delito.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal- quantidade elevada de pena e a reincidência - bem como diante da expressa proibição legal prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § único do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos réus, pois que se faz necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Tal como já ressaltado, os réus são reincidentes; soltos, por certo voltarão a praticar crimes. Há necessidade de se prevenir outras investidas, mantendo-os encarcerados, pois neste caso resta evidente que se trata de criminosos habituais. No mais, a pena aplicada a ambos é relativamente elevada, e o regime de pena é o mais gravoso. Soltos, por certo tentarão se furtar ao cumprimento desta pena, o que justifica sua custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar JEFERSON LINO CORREIA e HERNANDO MEDEIROS DA SILVA às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e para ABSOLVÊ-LOS do crime previsto no artigo 34 da mesma Lei, com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Expeçam-se mandados de prisão, recomendando-se onde se encontram.

Condeno os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual

Autorizo a destruição dos objetos apreendidos às fls. 27/28.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação ds réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 Lei de Tóxicos; d) expeça-se guia de execução penal.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA